

1501318-04.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

"TRÁFICO DE DROGAS Adolescente que indica a participação dos apelantes no tráfico Depoimentos dos policiais seguros, coerentes, sem desmentidos e confirmados pelas demais provas produzidas. Condenação mantida; Tráfico de drogas. Desclassificação para os crimes previstos nos artigos 35 e 37, da Lei nº 11.343/06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501318-04.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501318-04.2021.8.26.0617 2021/000780

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE DIANE DOS SANTOS ROSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

MATEUS HENRIQUE FERNANDES BATISTA e ALINE DIANE DOS SANTOS ROSA, o primeiro menor de 21 anos à época dos fatos, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 30.09.2021, por volta de 17h00, na Rua Alcídia Dias Pedrosa, Campos dos Alemães, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de desígnios entre si e com os adolescentes Reidison Jose de Oliveira da Conceição e Miguel Dantas do Nascimento, traziam consigo, sem autorização, para fins de tráfico, porções de cocaína, algumas sob a forma de crack; e porções de "maconha", substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificados os acusados para apresentação de defesa preliminar (fls. 128 e 130), veio aos autos à fl. 134.

Recebida a denúncia em 02.12.2021 (fls. 135/136), os réus foram citados pessoalmente (fls. 162 e 164). Em audiência, foi colhida prova oral e os acusados interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição dos acusados nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 37 da Lei de Drogas; a fixação da pena no mínimo legal, apontando ser a reincidência resquício do direito penal do autor, em relação à corrê ALINE; o afastamento da causa de aumento; o reconhecimento da atenuante relativa à idade do réu MATEUS; da confissão quanto a ambos os réus; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O corrêu MATEUS, interrogado perante a autoridade policial e em juízo, disse que estava atuando como "olheiro" entre o horário das 07h00 às 17h00, bem como receberia o valor de R\$ 200,00. Aceitou a oferta pois estava desempregado e precisando de dinheiro. Sua função era avisar a chegada da polícia (fl. 13 e arquivo digital).

ALINE, na etapa inquisitiva e em juízo, afirmou que é usuária de crack e exercia a função de "indica", entre o horário das 07h00 às 17h00, pelo valor de R\$.200,00. Apenas indicava onde era o ponto de venda de droga (fl. 20 e arquivo digital).

Os policiais militares JOSE APARECIDO MACHADO e ANDERSON JOSE DA COSTA MONTEIRO, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, flagraram os réus em plena traficância, confessando MATEUS, em cujo poder foi apreendido um aparelho de telefonia celular, exercer a função de "olheiro", e a ré a função de "indicadora". A droga e dinheiro foram apreendidos em poder dos adolescentes (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 97/98 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, que, como se sabe, são drogas.

A confissão dos réus, aliada às palavras dos policiais militares, que, durante patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, apreenderam expressiva quantidade e variedade de drogas e dinheiro na posse dos adolescentes R.J.O.C e M.D.N. (totalizando 28,39g de cocaína, em 34 pinos plásticos; 4,0g de crack, em 34 pedras; e 267,94g de "maconha", em 138 porções; R\$ 321,00), exercendo MATEUS a função de "olheiro" (em cujo poder foi apreendido um dos dois aparelhos de telefonia celular), cabendo a ALINE indicar aos usuários a localização da "biqueira", elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que os réus, traziam consigo, juntamente com os jovens, a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação dos réus nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

De fato, além de bem demonstrado o concurso de agentes para a prática do delito do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, não ficou caracterizada existência de grupo, associação ou organização destinado à prática do tráfico, cuidando-se de mero

concurso eventual de agentes, estando ausentes qualquer dessas elementares a autorizar a tipificação do delito do art. 37, caput, da Lei de Tóxicos.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

“TRÁFICO DE DROGAS Adolescente que indica a participação dos apelantes no tráfico Depoimentos dos policiais seguros, coerentes, sem desmentidos e confirmados pelas demais provas produzidas. Condenação mantida; Tráfico de drogas. Desclassificação para os crimes previstos nos artigos 35 e 37, da Lei nº 11.343/06 impossibilidade Inexistência de provas de que os réus tivessem qualquer informação privilegiada a colaborar com a associação para o tráfico Atuação que caracteriza divisão de tarefas no tráfico. Coautoria demonstrada Participação de menor importância Inocorrência Recursos providos em parte para a redução das penas.” (Apelação nº 0046537-51.2010.8.26.0564, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Alexandre Almeida, j. 24.04.2014).

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade dos acusados.

Resta fixar as reprimendas.

I- Corrêu MATEUS.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (total de 28,39g de cocaína, em 34 pinos plásticos; 4,0g de crack, em 34 pedras; e 267,94g de “maconha”, em 138 porções), além de quantia em dinheiro (R\$ 321,00) e 02 aparelhos de telefonia celular, tudo a revelar a intensidade do comércio espúrio.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Sendo o réu confesso (Súmula n. 545 do STJ) e menor de 21 anos à época dos fatos, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, afora 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, VI, majoro suas penas de

um sexto, ficando definitivamente estabelecidas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso.

Observo que o acusado admitiu haver respondido a feitos pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico quando adolescente, o que é corroborado pelos documentos de fls. 208/213 (processo nº 1500475-44.2018, oportunidade em que foi cominada definitivamente medida de semiliberdade), e de fls. 185/190 e 214/230 (processos nº 1501169-76.2019, nº 1513238-03.2018 e nº 1516102-43.2020 – oportunidades em que foram cominadas definitivamente a medida de internação). Além de os atos infracionais terem sido perpetrados entre os anos de 2018 a 2020, em data próxima, portanto, à presente infração penal, esta é a quinta vez que é flagrado traficando, não sendo traficante de "primeira viagem" ou eventual, não fazendo jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

Nessa esteira a mais recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 1. Embora o recente entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, seja pela impossibilidade de utilização, por si só, da existência de ações penais em curso para o afastamento da causa de diminuição da pena do tráfico, é possível a utilização de atos infracionais como parâmetro para o seu afastamento a depender do caso concreto, notadamente quando o número de atos infracionais, a gravidade e o tempo decorrido desde o cometimento indiquem dedicação a atividades criminosas. Presentes tais requisitos, inviável a aplicação da minorante (...)" (HC 674.746/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas pela mera quantidade de pena aplicada.

II- Corrê ALINE.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência específica (condenação referente ao processo nº 0000520-59.2017, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 14.08.2017 e para a Defesa em 03.08.2018 – fl. 63), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (total de 28,39g de cocaína, em 34 pinos

plásticos; 4,0g de crack, em 34 pedras; e 267,94g de "maconha", em 138 porções), além de quantia em dinheiro (R\$ 321,00) e 02 aparelhos de telefonia celular, tudo a revelar a intensidade do comércio espúrio.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica da acusada.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 545 do STJ), valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido" (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, VI, majoro suas penas de um sexto, ficando as reprimendas definitivamente estabelecidas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no piso.

Anoto que devido à reincidência específica da ré, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma que atende a todos os princípios jurídico-penais, não ofendendo a isonomia; antes, garantindo plena individualização da pena.

O regime inicial de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o fechado (art. 33, §2º, 'a' e § 3º, do Código Penal), conclusão não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas seja pela mera quantidade da pena aplicada, seja pela reincidência.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar como incursos nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06:

- a) MATEUS HENRIQUE FERNANDES BATISTA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado;
- b) ALINE DIANE DOS SANTOS ROSA, qualificada nos autos, a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (regime inicial fechado), além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Deverão os acusados permanecerem presos para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontram.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 02 de fevereiro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA